

1502309-26.2021.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502309-26.2021.8.26.0537 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502309-26.2021.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2316279/2021 - 03º D.P. DIADEMA, 21504738 - 03º D.P.

DIADEMA, 2316279 - 03º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

KAIQUE MARTINS DE OLIVEIRA SOARES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

KAIQUE MARTINS DE OLIVEIRA SOARES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, incisos II, e §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, c/c o artigo 61, inciso II, alínea "j", na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, porque no dia 20 de novembro de 2021, por volta das 16h45, na Rua do Boqueirão, nº 669, Jardim Colina, São Paulo - SP, em ocasião de calamidade pública, juntamente com o adolescente L. C. L. Z., agindo em concurso, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, 01 motocicleta Yamaha Mt03, placas DKH-0470,

avaliada em R\$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), 01 capacete da marca No Risk, avaliado em R\$800,00 (oitocentos reais) e 01 telefone celular, Samsung Galaxy A30, avaliado em R\$800,00 (oitocentos reais), todos pertencentes à vítima W. C. P. J. A denúncia foi recebida em 01 de dezembro de 2021 (fls. 77/78). O réu foi citado (fls. 154) e apresentou resposta à acusação (fls. 173/176).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas em comum pelas partes, bem como uma testemunha da defesa. O réu não foi interrogado, porque revel.

Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia. Em relação às penas, pleiteou a elevação da pena na terceira fase pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo e a fixação do regime fechado.

A defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas quanto ao roubo e por ausência de materialidade quanto ao crime de corrupção de menores.

Subsidiariamente, postulou a desclassificação do roubo para receptação, com fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ainda subsidiariamente, em caso de condenação, requereu o afastamento da causa de aumento de pena do emprego de arma e também da agravante da calamidade pública, bem como a manutenção das penas no mínimo legal, incidência da atenuante da menoridade relativa, aumento único na terceira fase em função do eventual reconhecimento de ambas as majorantes, a fixação de regime de pena diverso do fechado e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão estatal é procedente em parte.

A vítima afirmou que na data dos fatos, por volta das 16h45, conduzia sua motocicleta, quando parou no semáforo existente na Av. Tancredo Neves e foi abordado por dois indivíduos, que chegaram a pé, sendo que um deles portava uma arma de fogo, um revólver calibre 38 de cor preta. Eles exigiram a entrega da moto e de seu capacete, que foi removido de sua cabeça com agressividade. Seu celular também foi subtraído, porque estava afixado em um suporte no painel da moto. Em seguida, eles se evadiram do local. Acionou a Polícia Militar e fez um boletim de ocorrência junto ao 26º DP. Por volta da 01h do dia seguinte recebeu uma ligação de policiais, que informaram que haviam localizado uma moto e um capacete, sendo que lhe foram enviadas fotos de tais objetos para que os reconhecesse como seus, o que foi feito. Os policiais também enviaram fotos dos indivíduos abordados, mas estavam com as cabeças abaixadas, e não afirmaram que haviam detido os indivíduos que o haviam roubado, informando apenas que a chave da sua moto estaria em poder deles, solicitando apenas que comparecesse ao Distrito Policial de Diadema para proceder ao reconhecimento, o que foi feito. No local foram-lhe apresentados dois indivíduos, os quais o depoente reconheceu com absoluta certeza como sendo os autores do crime. Esclarece que eles trajavam as mesmas blusas do momento do crime. Recuperou sua moto com alguns danos e o seu capacete. Não recuperou o aparelho celular.

Os policiais militares relataram que estavam em apoio a unidades ROCAM que estavam em perseguição a uma moto, que havia sido roubado pouco antes, mas perderam tal moto de vista. Realizaram patrulhamento nas imediações de onde ocorreu a perseguição, dirigindo-se para uma travessa conhecida como ponto de tráfico e comumente utilizada para se esconderem veículos subtraídos. Em referida travessa avistaram dois indivíduos, que estavam perto um do outro e perto deles havia dois capacetes. Em revista pessoal, encontraram com o réu uma chave de moto marca Yamaha, sendo que a moto perseguida momentos antes era da mesma marca. Realizaram varredura nas proximidades, vindo a encontrar uma moto daquela marca em uma viela bem próxima. Ela estava com o motor quente e foi acionada com a chave encontrada em poder do réu. Retornaram ao local da abordagem com a moto, momento em que o réu e o menor apenas confirmaram que estavam em poder da moto, mas não confessaram a prática do roubo. A vítima foi acionada, mas os policiais não se recordavam exatamente como (o policial Marcio acreditava que o contato havia sido feito via COPOM e o policial Patrick disse que ele próprio teria ligado para a vítima). Não sabiam sobre o envio de fotos para a vítima. Não conheciam o réu e o menor anteriormente. Ninguém interveio em favor deles durante a abordagem. Havia duas

meninas perto deles, segundo Patrick, mas elas não intervieram durante a abordagem. Não se recordavam onde eles residiam.

A testemunha de defesa Lucas narrou que trabalha com o réu em um lava-rápido das 8 às 18 horas diariamente, com apenas uma folga semanal. Afirma que no dia dos fatos o réu trabalhou até o final do expediente.

O réu não foi interrogado porque é revel.

O conjunto probatório carreado aos autos autoriza o acolhimento da pretensão punitiva estatal em parte.

Assim, há prova suficiente quanto à autoria delitiva em desfavor do réu, que foi reconhecido com segurança pela vítima na fase policial, narrando com absoluta segurança na presente data quanto ao reconhecimento procedido naquela ocasião, o qual ocorreu pouco tempo depois do crime, quando a memória dos fatos ainda era muito viva. O reconhecimento pessoal em Juízo não foi possível, diante da negativa do réu em participar do ato ao se negar a deixar a cela em que se encontra recolhido. Vale destacar que esta narrou detalhadamente a dinâmica dos fatos, inclusive quanto ao momento da abordagem, realizada pelo réu e pelo menor, que portava a arma de fogo, sendo que chegaram a pé, anunciaram o assalto, subtraíram seus bens e fugiram com o réu conduzindo sua motocicleta, não havendo qualquer elemento a infirmar suas palavras. Ambos estavam com os rostos descobertos e ficaram muito próximos da vítima. O ofendido ainda informou que ambos ainda trajavam as mesmas blusas.

Some-se a isto o fato de que com o réu foi encontrada a chave da moto e o capacete da vítima estava ao seu lado. A moto foi encontrada, ainda com o motor quente, a poucos metros de onde o réu foi abordado. Momentos antes, guarnições da ROCAM estavam no encalço da moto, que acabou conseguindo se evadir.

Frise-se que o depoimento da vítima é suficiente para fundamentar o decreto condenatório, tendo em vista tratar-se de crime tipicamente cometido na clandestinidade, quando estão apenas o agente e o ofendido. Neste sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade." (STJ, AgRg no AREsp 297871/RN, Ministro CAMPOS MARQUES)

Anoto, ainda, que não é de se reconhecer qualquer irregularidade com relação ao reconhecimento procedido na fase policial por conta do envio de fotos dos abordados ao ofendido. Com efeito, em primeiro lugar, a vítima narrou que sequer conseguiu visualizar os rostos dos indivíduos, que estavam de cabeças baixas. Em segundo lugar, a vítima foi clara ao relatar que não houve qualquer tentativa de induzimento por parte dos policiais, que esclareceram que era necessário que ela fosse ao Distrito Policial para proceder ao reconhecimento pessoal.

E os policiais ouvidos procederam a relatos detalhados, uníssonos e harmônicos entre si, ratificando-se o que falaram na fase policial, nada havendo nos autos que possa extrair a validade de suas palavras. Trata-se de agentes públicos, dotados de fé pública, aos quais são conferidos poderes para fins de polícia preventiva e repressiva, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor. As divergências havidas nos depoimentos são pontuais e não maculam em nada os depoimentos prestados, sendo que apenas indicam que tais policiais prestaram depoimentos firmes e fidedignos, baseados em suas lembranças, pois se houvesse absoluta coincidência, sem qualquer divergência, ainda que sobre aspectos relevantes, é que se poderia ter desconfiança de que se concertaram previamente.

A palavra deles não merece descrédito, inexistindo motivos para que eles pretendessem legitimar a prisão realizada. São agentes públicos dotados de

presunção de boa-fé, até prova em contrário, cuja produção estaria a cargo da defesa, que não se desincumbiu de tal ônus nestes autos. Não seria coerente conferir-se ao policial a presunção de legitimidade para realizar as funções que lhe compete, como a de policiamento ostensivo e abordagem a suspeito, para depois, em Juízo, extrair-se de suas palavras a validade necessária. Esclarecedora a seguinte transcrição

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO. (...).

2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso" (STJ, HC 165561 / AM, rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 02/02/2016).

No mais, o depoimento da testemunha de defesa não tem o condão de afastar a higidez das demais provas produzidas, pois se tratou de um depoimento vago, sem qualquer especificação e justificativa. O documento de fls. 178 apenas relata a rotina de trabalho do réu, sem especificar dias de trabalho e folga.

Com efeito, o concurso de agentes restou devidamente demonstrado pelos depoimentos da vítima, que detalhou a dinâmica fática e as condutas dos roubadores, restando inegável o prévio ajuste, a unidade de designios e a divisão de tarefas, existindo o vínculo psicológico entre os roubadores.

Ademais, o emprego de arma de fogo restou devidamente demonstrado, já que a vítima foi clara quanto ao fato de que houve o emprego de arma de fogo, um revólver calibre 38, que foi colocado muito próximo de seu rosto. Vale destacar ser desnecessária a apreensão desta para a incidência da causa de aumento de pena.

Neste sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência 961.863/RS, firmou entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. 2. No caso, embora a arma não tenha sido apreendida e periciada, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, concluíram pela sua efetiva utilização na empreitada criminosa, afigurando-se legal a incidência da respectiva majorante no crime de roubo. 3. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp 1221290/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018).

Observe que os fatos ocorreram após o advento da Lei nº 13.654/18, que passou a prever o emprego de arma de fogo como causa de aumento de pena em parágrafo destacado das demais causas de aumento de pena, com índice superior de majoração. Com tal alteração legal e havendo a incidência de causas de aumento de pena previstas em parágrafos distintos, como ocorre no presente caso, é o caso de aplicação do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, com incidência apenas da causa que mais aumenta (no caso, o emprego de arma de fogo). A outra causa (concurso de agentes) será considerada como circunstâncias judicial na primeira fase da dosimetria, na medida em que torna a circunstância do crime mais grave, já que o concurso de agentes não apenas facilita o cometimento do delito, como também inviabiliza qualquer capacidade de reação da vítima, dando maior garantia de impunidade e segurança na fuga.

Por seu turno, no que tange ao crime de corrupção de menor, não se ignora o

pacífico entendimento de que se trata de delito formal, bastando que haja comprovação de que o delito tenha sido praticado em companhia de um menor, não havendo necessidade de comprovação de que fora efetivamente corrompido. Todavia, no presente caso, observa-se que o réu possuía apenas 18 anos de idade e o menor Luiz, com quem teria praticado o roubo em questão, já se encontrava próximo de completar 16 anos (fls. 11), não havendo como se atestar corrupção ou facilitação deste, a fim de que praticasse ou fosse induzido a praticar o roubo, porquanto inegável a inexistência de qualquer hierarquia entre os indivíduos, quando, em verdade, aparentam ser conhecidos ou amigos que, infelizmente, decidiram conjuntamente praticar a infração penal. Ademais, em consulta ao sistema SAJ, constata-se que o menor ostenta um processo (1502390-86.2021.8.26.0015), nos quais houve aplicação de medida socioeducativa de internação.

Por tais motivos, a despeito de o entendimento particular desta magistrada ser no sentido dos Tribunais Superiores, excepcionalmente, afasto a imputação da corrupção de menores no presente caso.

Por fim, quanto à agravante da calamidade pública descrita na denúncia, muito embora esta magistrada viesse reconhecendo a sua incidência em todos os crimes praticados desde a edição do Decreto que reconheceu tal situação no país, após inúmeras reformas de suas decisões pelo E. TJSP e também pelo E. STJ, admite-se ser o caso de se curvar ao entendimento superior para se evitar recursos desnecessários. Com efeito, os tribunais fixaram o entendimento quase pacífico no sentido de que há necessidade de demonstração de nexos causal entre a conduta do réu e a calamidade pública decorrente da pandemia, devendo haver demonstração concreta de que o acusado se valeu de tal situação para cometer o crime. Tal não ocorre nos presentes autos, de modo que não é o caso de se reconhecer a incidência da agravante em questão.

Desta forma, forçosa a condenação do réu nos termos acima dispostos. Passo à DOSIMETRIA DA PENA.

As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis ao réu, nos termos acima referido, considerando-se a atuação em concurso de agentes, razão pela qual suas penas serão elevadas em 1/6, ficando estabelecidas em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e presente a atenuante da menoridade relativa, as penas retornam ao mínimo legal, sendo inviável a redução aquém do mínimo, conforme Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, as penas devem ser elevadas em 2/3, ficando estabelecidas em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

Em que pese a primariedade do réu, entende-se que o regime inicial de cumprimento de pena deva ser o fechado, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal. Com efeito, além da quantidade de pena, o cometimento do delito em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo recomenda a adoção de tal regime prisional, eis que tais circunstâncias demonstram maior periculosidade por parte dos agentes, que se utilizam de artifícios que vão além da conduta simplesmente prevista pelo legislador, visando à garantia da empreitada criminosa, o que importa, também, maior risco para as vítimas.

O crime tratado nos autos é de suma gravidade, daqueles que mais desassossego trazem aos cidadãos de bem desta cidade, os quais se encontram acuados pela ação delituosa cada vez mais presente em seu cotidiano, decorrência da ineficiência da estrutura de segurança pública. O Poder Judiciário não pode responder da mesma forma ao criminoso que comete um crime de tal natureza àquele que pratica crime menos grave para a sociedade, embora punido com igual rigor pelo legislador. Como visto, tratou-se de crime com gravidade concreta, tendo em conta que, atuando em conjunto com outro indivíduo, realizaram a abordagem munidos de uma arma de fogo e subtraíram os bens da vítima, restando certo que tal atuação representava maior periculosidade e menor capacidade de reação, facilitando a consumação delitiva. Por isso, entende-se que outro não pode ser o regime inicial de cumprimento da pena. Deixo de aplicar o artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, com a redação dada

pela Lei nº 12.736/2012, por entender que tal dispositivo é impossível de ser aplicado no Juízo de primeiro grau. A progressão de regime é matéria atinente ao Juízo das execuções criminais, devendo ser aferido não apenas o tempo de cumprimento da pena, como também se o sentenciado possui mérito para a progressão. Além disso, considero tal dispositivo inconstitucional, uma vez que viola os princípios da isonomia e da individualização da pena. Ao se considerar somente o tempo de prisão provisória para a fixação do regime inicial, aquele que ficou solto durante o processo é tratado de forma prejudicial com relação àquele que ficou preso, uma vez que este poderá ter direito ao regime inicial mais benéfico tendo como base apenas o tempo de pena cumprido provisoriamente.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão estatal para o fim de CONDENAR, por infração ao artigo 157, §2º, incisos II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, KAIQUE MARTINS DE OLIVEIRA SOARES, às penas de em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no mínimo legal. Outrossim, ABSOLVO-O da imputação de infração ao artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, o que faço com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

As mesmas razões que recomendaram a custódia do acusado no curso do feito permanecem ainda presentes, vendo-se ainda reforçada a necessidade da cautela uma vez que, determinada a imposição de elevada pena ao acusado, patente o risco de que solto venha procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomende-se o réu no estabelecimento em que se encontra recolhido.

Custas na forma da lei.

Com o trânsito em julgado da presente sentença, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário para o cumprimento da pena.

P.R.I.C.

São Paulo, 03 de fevereiro de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA